

《【문제5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음1) 甲이 제기한 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일한지 여부에 대하여 판례의 입장인 구실체법설(구이론)에 근거하여 논하고, 이에 따른 후소의 적법성 여부를 판단하십시오.》

<문제5.4의 물음1> 구실체법설에 따른 전후소 소송물의 동일성 여부 및 후소의 적법성 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 X 토지에 관한 매매계약의 취소를 원인으로 소유권이전등기말소를 청구하였다가 패소확정된 후, 다시 동일한 토지에 대하여 매매계약의 무효를 원인으로 소유권이전등기말소를 청구하는 후소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <동일한 청구취지 아래 취소에 따른 원상회복청구권과 무효에 따른 원상회복청구권이 판례의 구실체법설상 동일한 소송물인지 및 이에 따라 후소가 기판력에 저촉되어 적법한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 구실체법설에 따른 소송물의 동일성 및 후소의 적법성 여부를 판단한다.

II. 소송물 이론과 구실체법설

1. 소송물 이론의 의의

- 소송물 이론은 소송의 대상을 어떻게 확정할 것인가에 관한 논의로서, 이는 중복소제기 금지, 처분권주의의 범위, 청구의 변경, 기판력의 범위를 결정하는 기준이 된다.

2. 구실체법설(구이론)

(1) 내용

- 실체법상의 권리 또는 법률관계를 기준으로 소송물을 확정하는 견해다. 즉, 실체법상 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 본다.

(2) 판례의 입장

- 우리 “대법원”은 원칙적으로 구실체법설의 입장을 견지하고 있다. 따라서 실체법상 권리가 다르면 청구취지가 동일하더라도 소송물은 별개라는 것이 확립된 태도다.

III. 소송물의 동일성 여부 검토

1. 물권적 청구권과 소송물

(1) 소유권에 기한 방해배제청구권

- “판례”는 소유권에 기한 말소등기청구소송에서 그 등기원인의 무효 사유가 다르더라도 소송물은 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 하나라고 본다. 따라서 전소에서 주장하지 않은 무효 사유를 후소에서 주장하는 것은 소송물의 변경이 아니라 공격방어방법의 변경에 불과하다.

(2) 예외 : 청구권원 자체가 다른 경우

- 만약 전소는 계약상의 채권적 청구권이고 후소가 물권적 청구권이라면 이는 실체법상 권리가 다르므로 소송물이 별개로 취급된다.

2. 사안의 경우

(1) 전소의 소송물

- 甲은 취소에 따른 원상회복으로서 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 주장하였다. 이는 실체법상 소유권에 기한 방해배제청구권에 해당한다.

(2) 후소의 소송물

- 甲은 무효에 따른 원상회복을 주장하며 다시 말소등기를 청구하였다. 취소와 무효는 그 원인은 다르지만, 결국 실체법상으로는 동일한 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사하는 것이다.

(3) 검토

- “판례”의 태도에 의하면 등기원인의 무효 사유(취소 또는 무효)는 공격방어방법에 불과하므로, 전소와 후소의 소송물은 동일하다.

IV. 후소의 적법성 판단

1. 기판력의 의의 및 범위

(1) 의의

- 확정판결의 판단 내용이 후소의 법원을 구속하여 당사자가 이와 모순되는 주장을 할 수 없게 하는 효력이다.

(2) 시적 범위

- 기판력은 사실심 변론종결 시를 기준으로 발생한다. 당사자는 변론종결 전의 사유를 후소에서 다시 주장할 수 없다.

2. 기판력의 저촉 여부

- 사안의 전소 판결은 기각되어 확정되었다. 후소는 전소와 동일한 소송물(소유권에 기한 말소등기청구권)을 대상으로 하므로 전소 판결의 기판력이 미친다. 甲이 후소에서 주장하는 매매계약의 무효 사유는 전소의 변론종결 전에 이미 존재하던 사유이므로, 이를 뒤늦게 주장하는 것은 기판력의 차단효에 의해 허용되지 않는다.

V. 결론

- 구실체법설을 취하는 “판례”에 의할 때, 전소와 후소는 모두 소유권에 기한 물권적 청구권으로서 소송물이 동일하다. 따라서 후소는 전소의 확정판결의 기판력에 저촉된다. 법원은 기판력에 저촉되는 후소에 대하여 청구기각 판결을 내려야 한다는 것이 “판례”의 일반적인 태도다. 다만, 최근에는 소송요건으로 보아 소를 부적법각하해야 한다는 견해도 있으나, “판례”는 대체로 실체적 판결로서 기각하는 방식을 취한다. 결론적으로 甲의 후소는 전소의 효력에 반하여 허용될 수 없다.